

刑法  
No347

R1-2

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの個数を後記1から5までのの中から選びなさい。

## 【事例】

甲及び乙は、宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は、甲が、宝石取引のあつせんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し、別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って丙から宝石を受領し、甲の退室後に、乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。

甲は、計画に従って、ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し、それと入れ替わりに同室に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせたが、殺害には至らなかった。

## 【記述】

ア. 甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合、甲及び乙に、事後強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。

イ. 甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合、同一の被害を二重に評価することはできないため、甲及び乙が、丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても、甲及び乙に、殺人未遂罪が成立するにとどまり、いわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。

ウ. 甲及び乙が、丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても、丙がこれを免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため、甲及び乙に、いわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。

エ. 乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が、丙から宝石の占有を奪取する手段とらないと考えた場合、甲及び乙に、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。

1. 0個      2. 1個      3. 2個      4. 3個      5. 4個

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| No347 | 強盗殺人未遂罪 | 正答率<br>61% |
| R1-2  | 正解 3    |            |

## ア 正しい

238 条は、事後強盗の主体について、「窃盗が」と定めている。よって、詐欺罪が成立する甲及び乙に事後強盗罪は成立し得ない。

## イ 誤っている

最決昭 61.11.18 (百選Ⅱ 40 事件) は、本記述と同様の事案において、「被告人による拳銃発射行為は、B を殺害して同人に対する本件覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の支払を免れるという財産上不法の利益を得るためになされたことが明らかであるから、右行為はいわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪に当たるといふべきであり、……先行する本件覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と(二項)強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当である。」としている。よって、甲及び乙の行為には、二項強盗による強盗殺人未遂罪が成立し得る。

## ウ 誤っている

最判昭 32.9.13 (百選Ⅱ 39 事件) は、本記述と類似の事案において、「犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく刑法 236 条 2 項の不法利得罪を構成する」としている。

## エ 正しい

東京高判昭 48.3.26 は、236 条 1 項の「強盗罪は相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行または脅迫を手段として財物を奪取することによつて成立する犯罪である」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、強盗罪は、財物奪取の手段として暴行・脅迫を用いる点にその本質の特徴があるということを挙げている。本記述では、乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が、丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えるため、一項強盗罪の手段としての暴行・脅迫が他に存在しないことになり一項強盗罪は成立しない。そのため、一項強盗罪による強盗殺人未遂罪が成立することはない。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって正解は肢 3 となる。